

<제2편 소송의 주체.제4장 당사자.제3절 소송상의 대리인>

I. 서설

1. 소송상의 대리인의 의의

- 소송상의 대리인이란 당사자의 이름으로 소송행위를 하거나 소송행위를 수령함으로써 그 효과를 직접 당사자에게 귀속시키는 제3자를 의미한다. 이는 당사자가 소송무능력자이거나 법률 지식이 부족한 경우, 또는 신속한 절차 진행을 위해 대리인의 조력을 받을 필요가 있을 때 활용되는 제도이다.

2. 소송상의 대리인의 종류

- 소송상의 대리인은 대리권의 발생 원인에 따라 법정대리인과 임의대리인으로 구분된다. 법정대리인은 본인의 의사와 관계없이 법률의 규정 등에 의해 대리권이 발생하는 자이며, 임의대리인은 본인의 수권행위에 의해 대리권이 발생하는 자이다. 또한 소송물인 권리관계와 관련하여 포괄적인 권한을 갖는가에 따라 포괄적 대리인과 개별적 대리인으로 나뉘기도 한다.

II. 법정대리인

1. 의의

- 법정대리인이란 본인의 의사에 의하지 않고 법률의 규정이나 법원의 선임 등에 의하여 대리권이 발생하는 소송대리인을 말한다. 미성년자나 성년후견대상자와 같은 소송무능력자를 보호하고 소송절차의 원활한 진행을 도모하기 위해 존재한다.

2. 법정대리권의 발생

(1) 실체법상 법정대리인

- 민법 등 실체법상의 규정에 의하여 당연히 대리권이 발생하는 경우이다. 친권자나 성년후견인 등이 이에 해당하며, 이들은 별도의 선임 절차 없이 법률상 지위에 따라 소송대리권을 갖는다.

(2) 소송법상 특별대리인

- 소송무능력자에게 법정대리인이 없거나 대리권을 행사할 수 없는 경우, 소송 지연으로 인한 손해를 방지하기 위해 법원이 선임하는 대리인이다(민소법 제62조). 이는 당해 소송에 한하여 한시적으로 대리권을 가진다.

(3) 법인 등 대표자

- 법인이나 비법인사단의 대표자는 성질상 법정대리인에 관한 규정이 준용된다(민소법 제64조). 이들은 법인 등기부상의 기재나 정관에 정해진 선임 절차를 통해 대표권을 취득한다.

3. 법정대리권의 범위[민소법 제56조]

(1) 실체법상 법정대리인

- 실체법상 법정대리인은 본인을 위하여 소송행위에 관한 포괄적인 대리권을 가진다. 다만, 상대방이 제기한 소송이나 상소에 대응하는 응소행위는 제한 없이 가능하나, 본인을 위해 소를 제기하거나 화해, 포기, 인낙 등 실체적 권리에 영향을 미치는 행위는 민법상 제한(가족법상의 동의 등)이 있는 경우 그에 따라야 한다.

(2) 소송법상 특별대리인

- 특별대리인은 본인을 위하여 해당 소송의 모든 소송행위를 할 권한을 가진다. 다만, 후견인에 관한 규정이 준용되므로 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙 등 중요한 처분행위를 할 때에는 법원이나 감독인의 허가를 얻어야 한다.

(3) 법인 등 대표자

- 법인의 대표자는 법인의 업무 전반에 관하여 포괄적인 대표권을 가지며, 소송에서도 제한 없는 대리권을 가진다. 정관이나 이사회 결의로 대표권을 제한하더라도 소송법상으로는 선의의 제3자(상대방 당사자)에게 대항할 수 없다.

(4) 공동대리

- 법정대리인이 여러 명인 경우(예 : 부모의 공동친권) 원칙적으로 공동으로 대리권을 행사하여야 한다. 다만, 상대방의 소송행위를 수령하는 수동대리에 있어서는 각자가 본인을 대리할 수 있다.

4. 법정대리인의 지위

(1) 제3자의 지위

- 법정대리인은 소송의 당사자가 아닌 제3자이다. 따라서 증인능력을 가지며, 본인에 대한 판결의 기판력은 법정대리인 개인에게 미치지 않는다.

(2) 본인에 유사한 지위

- 법정대리인의 소송상 행위는 본인의 행위와 동일한 효력을 가지므로, 그가 알고 있는 사정은 본인이 알고 있는 것과 같이 취급된다. 또한 법정대리인은 본인을 대신하여 자백하거나 증거조사에 참여할 수 있는 등 실질적으로 당사자와 유사한 지위에서 소송을 주도한다.

5. 법정대리권의 소멸

(1) 대리권 소멸원인

- 본인의 사망, 대리인의 사망·결격사유 발생, 본인의 소송능력 회복(예 : 미성년자의 성년 도달) 등이 소멸 원인이 된다.

(2) 대리·대표권소멸통지

- 법정대리권이 소멸하더라도 그 사실을 상대방 당사자에게 통지하지 않으면 대리권 소멸의 효력을 주장할 수 없다(민소법 제63조). 이는 소송절차의 안정을 보호하기 위함이다.

III. 임의대리인

1. 의의

- 임의대리인이란 당사자 본인의 수권행위(소송위임 등)에 의하여 대리권을 취득하는 자를 말한다. 변호사가 가장 전형적인 예이다.

2. 법률상의 소송대리인

- 본인의 의사에 기하여 선임되었으나 그 대리권의 범위가 법률에 규정되어 있는 자를 의미한다. 상법상의 지배인이나 선박관리인 등이 이에 해당하며, 이들은 본인의 영업에 관한 소송에서 포괄적인 대리권을 가진다.

3. 소송위임에 의한 소송대리인

(1) 의의

- 당사자가 특정 소송을 수행하기 위하여 특정인을 대리인으로 선임하는 경우이다. 이를 통상 소송대리인이라 부른다.

(2) 소송대리인의 자격

- 민사소송법은 변호사 대리의 원칙을 채택하고 있어 원칙적으로 변호사만이 소송대리인이 될 수 있다(민소법 제87조). 다만, 단독판사가 심리하는 소액사건 등 예외적인 경우에는 당사자와 밀접한 관계가 있는 친족이나 고용관계에 있는 자가 법원의 허가를 얻어 대리인이 될 수 있다.

(3) 소송대리권의 발생

- 본인과 대리인 사이의 소송위임 계약과 법원에 대한 위임장 제출로 발생한다.

(4) 소송대리권의 범위[민소법 제90조]

- 소송대리인은 위임받은 사건에 대하여 일체의 소송행위를 할 수 있는 포괄적 권한을 가진다. 반소의 제기, 응소, 강제집행에 관한 행위 등이 포함된다. 다만, 반소 제기, 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 상소의 제기·취하 등 당사자의 실체적 이익에 중대한 영향을 미치는 행위는 특별수권이 있어야만 가능하다.

(5) 소송대리인의 지위

- 소송대리인은 본인의 이름으로 행위하되 독립하여 소송을 수행한다. 여러 명의 대리인이 있는 경우에도 각자가 본인을 대리하는 각자대리의 원칙이 적용된다. 소송대리인의 자백은 본인이 기일에 출석하여 지체 없이 취소하거나 경정하지 않으면 본인의 자백으로서 효력을 갖는다.

(6) 소송대리권의 소멸

- 본인이나 대리인의 사망, 파산 등이 소멸 원인이다. 그러나 소송위임에 의한 대리권은 본인이 사망하거나 소송능력을 상실하더라도 소멸하지 않는다는 특칙이 있다(민소법 제95조). 이는 소송절차의 중단을 방지하고 연속성을 보장하기 위함이다.

IV. 무권대리인

1. 의의

- 무권대리인이란 대리권이 없음에도 불구하고 당사자의 이름으로 소송행위를 하는 자를 말한다. 소송법상 대리권의 존재는 소송요건이므로 무권대리인의 행위는 원칙적으로 무효이다.

2. 소송상 취급

(1) 소송요건

- 대리권의 존부는 법원의 직권조사사항이다. 법원은 대리권에 의심이 있는 경우 자명한 증거를 요구하거나 보정을 명하여야 한다.

(2) 소송행위의 유효요건

- 무권대리인이 행한 소송행위는 무효이나, 당사자 본인이 이를 추인하면 소급하여 유효하게 된다. 추인은 명시적이어야 할 필요는 없으나, 소송 전반에 걸친 묵시적 승인으로 해석될 수 있는 행위가 있어야 한다.

3. 쌍방대리의 금지

(1) 쌍방대리행위

- 한 사람이 원고와 피고 쌍방을 대리하여 소송을 수행하는 것은 금지된다. 이는 이해상충을 방지하고 공정한 재판을 보장하기 위함이다.

(2) 변호사법 제31조 제1항 위반의 대리행위

- 변호사가 상대방으로부터 수임을 받거나 이해관계가 대립하는 사건에 관여하는 것은 금지된다. 이를 위반한 대리행위는 원칙적으로 무효이며, 상대방이 이익을 제기할 경우 법원은 해당 대리인을 절차에서 배제하여야 한다.

4. 표현대리의 법리적용 여부

(1) 학설

- 민법상의 표현대리 규정이 소송법에도 적용되는지에 대해 견해가 대립한다. 긍정설은 거래의 안전과 신뢰 보호를 중시하며, 부정설은 소송절차의 명확성과 안정성을 중시한다.

(2) 판례

- 판례는 원칙적으로 민사소송법상 소송행위에는 민법상의 표현대리 규정이 적용되지 않는다는 입장이다. 소송행위는 법원이 직권으로 그 유효성을 판단하여야 하는 공법적 행위이므로, 외관만으로 대리권의 효력을 인정할 수 없다고 본다. 따라서 무권대리인의 소송행위는 본인의 추인이 없는 한 절대적 무효이다.

(3) 검토

- 소송절차는 획일적이고 명확해야 하므로, 개별적인 신뢰 보호를 이유로 불확실한 대리권의 효력을 인정하는 것은 타당하지 않다. 따라서 판례와 같이 표현대리 적용을 부정하고 추인을 통해서만 구제하는 것이 법적 안정성에 부합한다.

V. 결론

- 소송상의 대리인 제도는 당사자의 능력을 보완하고 재판의 전문성을 높여 사법 정의를 실현하는 중추적 역할을 수행한다. 법정대리인은 무능력자의 권리를 보호하며, 임의대리인은 당사자의 자율적 선택에 기해 최선의 방어권을 행사하게 한다. 특히 소송대리권의 범위와 소멸에 관한 법리는 절차의 중단 없는 진행과 당사자의 실체적 권리 보호 사이의 균형을 맞추는 데 초점이 맞춰져 있다. 법원은 대리권의 존부를 엄격히 심사하여 무권대리에 의한 피해를 방지하는 동시에, 표현대리 배제 원칙 등을 통해 소송절차의 명확성을 유지함으로써 공정한 재판이 이루어질 수 있도록 감독하여야 할 것이다.